Universität St.Gallen

# Prüfungsbooklet Assessment

## Rechtswissenschaft I B

### Teil Schindler

**Hinweise:**

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

# Prüfung Assessment-Jahr – Sommer 2022

## Teil Prof. Schindler

**Name:** | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

**2,170**

Prüfungsteil: **Prof. Dr. B. Schindler (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. B. Schindler

**Bemerkungen:**

Dieser Prüfungsteil umfasst **4 Aufgaben auf 12 Seiten** (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

| | |
|---|---|
| 1. Aufgabe | 26 Punkte |
| 2. Aufgabe | 22 Punkte |
| 3. Aufgabe | 19 Punkte |
| 4. Aufgabe | 23 Punkte |
| **Total** | **90 Punkte** |

**Schreiben Sie direkt auf die Antwortblätter; sollten Sie Zusatzblätter benötigen, verwenden Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt.**
**Begründen Sie jede Antwort und nennen Sie die einschlägigen Rechtsnormen!**

# Aufgabe 1 — 26 Punkte

*Der Sachverhalt ist frei erfunden!*

Jasmine Bader ist Nationalrätin aus dem Kanton Z. In den Jahren 2020 und 2021 hat sie sich stark für die Anliegen von Gewerbetreibenden eingesetzt, die infolge der Covid-19-Pandemie teils massive Umsatzeinbussen zu gewärtigen hatten (beispielsweise Restaurants). Bader fand es ungerecht, dass solchen Gewerbetreibenden in gewissen Kantonen zumindest ein Teil der Miete erlassen wurde – in anderen dagegen nicht. Eine gesamtschweizerisch-einheitliche Lösung lehnte die Bundesversammlung Ende 2020 ab.
Nun will Bader aber im Sommer 2022 im Nationalrat einen neuen Versuch starten, damit zumindest in einer allfälligen nächsten Pandemiewelle eine schweizweite Regelung bereitstünde. Bader schwebt dabei folgende Regelung vor, die sie in einem Bundeserlass verankern möchte:

*Mieter von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben, die aufgrund von Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung von Pandemien schliessen mussten, schulden dem Vermieter während der Dauer der verordneten Schliessung in Abweichung von den Bestimmungen des Obligationenrechts 40 Prozent des vereinbarten Mietzinses.*

**Frage 1**: [12 Punkte]
Bereits im Jahr 2020 wurde immer wieder die Frage aufgeworfen, ob für eine solche Bundeslösung überhaupt eine genügende Bundeskompetenz bestünde. Bader (selbst keine Juristin) will die Sache vor der Lancierung des Vorstosses noch abklären und wendet sich deshalb an Sie. Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen. Ordnen Sie Baders Vorstoss anschliessend thematisch ein und beurteilen Sie, ob der Vorstoss mit der geltenden verfassungsmässigen Kompetenzordnung vereinbar wäre.

***Hinweis***: Es ist ***nicht*** zu prüfen, ob der Inhalt des Vorstosses gegen andere Bestimmungen der Bundesverfassung (beispielsweise die Grundrechte) verstösst.

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund nur zuständig, soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Dies entspricht auch dem Gedanken der Subsidiarität, der in Art 5*a* BV festgehalten ist; er ist aber nur eine «politische Klugheitsregel» und vermag die realen Kompetenzen nicht zu beeinflussen.

Baders Vorstoss kann verschiedenartig eingeordnet werden.

Erstens kann argumentiert werden, dass er Mietverhältnisse zwischen Privaten betrifft, die im Obligationenrecht geregelt sind (**1 Punkt**). Damit wäre der Vorstoss dem Zivilrecht zuzurechnen (vgl. Art. 122 BV) (**0.5 Punkte**). In diesem Bereich hat der Bund eine umfassende Bundeskompetenz (**1 Punkt**). *So Felix Uhlmann, Gutachterliche Stellungnahme, Rz. 1 ff.*

Zumindest denkbar ist auch die Argumentation, dass es einem Missbrauch gleichkomme, wenn Vermieter von Geschäftsräumlichkeiten bei angeordneten Schliessungen nicht von sich aus auf einen Teil des Mietzinses verzichten (**1 Punkt**). Damit wäre der Vorstoss bei Art. 109 BV einzuordnen, der sich auf Missbräuche im Mietwesen bezieht (**0.5 Punkte**). In diesem speziellen Bereich des Mieterschutzes kommt dem Bund ebenfalls eine Bundeskompetenz zu (**1 Punkt**) (vgl. Art. 109 BV). *So Karlen/Rüssli, Jusletter 12. Oktober 2020, Rz. 36*. A.A. *der Bundesrat in der Botschaft von 2020 (BBl 2020 8335).*

***Auch akzeptiert als Kompetenzgrundlage: 118 II lit. b BV oder Art. 95 als Einschränkung privatwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit***

Der Bundesrat wollte das Gesetz im Jahr 2020 dagegen auf Art. 100 BV abstützen (**1 Punkt**) (*BBl 2020 8335 f.*). Er verstand die Massnahme als konjunkturpolitisch (**1 Punkt**). Art. 100 Abs. 1 BV weist dem Bund in diesem Bereich eine umfassende Bundeskompetenz mit nachträglich derogatorischer Wirkung zu (**1 Punkt**)

**Fazit:** Vorstoss ist mit der geltenden verfassungsmässigen Kompetenzordnung vereinbar (gegenteiliges Fazit bei überzeugender Begründung akzeptiert) **(1 Punkt).**

**Frage 2**: [6 Punkte]
Gehen Sie davon aus, dass der Bund kompetent ist, die von Jasmine Bader geforderte Bestimmung zu erlassen. Begründen Sie, ***auf welcher Normstufe*** eine solche Regelung angesiedelt werden müsste.

***Hinweis***: Notverordnungen sind nicht zu prüfen.

Gemäss dem Erfordernis der Gesetzesform sollen alle für ein Gemeinwesen wichtigen Normen mindestens in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten sein (vgl. Art. 164 Abs. 1 BV). (**1 Punkt**), d.h. einem Gesetz, das vom Parlament verabschiedet wurde und dem Referendum unterstand (**1 Punkt**)

Art. 164 Abs. 1 BV nennt beispielhaft Bereiche, die als «wichtig» gelten.
- lit. b und c thematisieren. (**1 Punkt**)

Mögliche Begründungen: (**2 Punkte**)
- Einschränkung der Eigentumsgarantie. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV
- Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit
- Abweichen von Gesetzesbestimmungen (Obligationenrecht) → braucht ebenfalls Gesetzesrang.

**Fazit:** Die Regelung muss auf Stufe des (Bundes-)Gesetzes erlassen werden (**1 Punkt**). (Bei überzeugender Begründung wurde auch akzeptiert, dass die Regelung auf Stufe Verordnung erlassen werden soll.)

**Frage 3**: [8 Punkte]
Begründen Art. 76 Abs. 1 und/oder 3 BV eine Bundeskompetenz, und falls ja, welcher Art (***Kategorisierung nur nach Umfang und Staatsfunktion***)?

***Hinweis***: Beantworten Sie die Frage unabhängig vom Sachverhalt auf Seite 2.

Art. 76 Abs. 1 BV begründet für sich alleine keine Bundeskompetenz (**1 Punkt**). Der Wortlaut («im Rahmen seiner Zuständigkeiten») deutet aber auf eine fragmentarische Bundeskompetenz hin, die in den darauffolgenden Absätzen konkretisiert wird. (**1 Punkt**).

Art. 76 Abs. 3 BV begründet dagegen eine Bundeskompetenz (**1 Punkt**), wie sich ebenfalls aus dem Wortlaut ergibt («Er [der Bund] erlässt Vorschriften über») (**1 Punkt**).

Ein weiteres Indiz ist die systematische Stellung der Bestimmung (3. Titel, 2. Kapitel) (**1 Punkt**).

Vom Umfang her ist die Kompetenz in den genannten Bereichen umfassend (**1 Punkt**), worauf der Wortlaut deutet («erlässt Vorschriften») (**0.5 Punkte**). (Alternativ kann argumentiert werden, dass dem Bund eine fragmentarische Kompetenz im Bereich Wasser zukommt).

Art. 76 BV äussert sich nicht explizit zur Staatsfunktion (**0.5 Punkte**). Es kommt damit der Normalfall gemäss Art. 46 BV zum Zuge (**0.5 Punkte**). Mit anderen Worten obliegt der Vollzug den Kantonen, soweit der Bundesgesetzgeber den Vollzug nicht dem Bund vorbehält (**0.5 Punkte**).

# Aufgabe 2 — 22 Punkte

Das Schweizer Stimmvolk nahm am 7. März 2021 die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» an, womit die Bundesverfassung um Art. 10*a* BV ergänzt wurde. Nehmen Sie an, dass die Bundesversammlung in Ausführung dieser Bestimmung das «Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot» mit folgendem Wortlaut erlässt:

**Art. 1**
Wer sein Gesicht in der Öffentlichkeit verhüllt, wird mit Busse bestraft.

**Art. 2**
Die Gesichtsverhüllung ist aus Gründen der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums ausnahmsweise zulässig.

**Art. 3**
Für den Vollzug dieses Gesetzes sind die Kantone zuständig.

**Frage 1:** [5 Punkte]
Wie vollziehen Bundesstaaten Bundesrecht? Unterscheiden und erläutern Sie zwei Grundmodelle. Welchem Modell folgt das Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot?

Bundesstaaten folgen zwei unterschiedlichen Modellen, was den Vollzug von Bundesrecht anbelangt. Das schweizerische Modell des Vollzugsföderalismus («marble cake» federalism) (**1 Punkt**) überlässt den Vollzug im Regelfall den Gliedstaaten (vgl. Art. 46 BV) (**1 Punkt**). In den USA herrscht dagegen ein Modell des dezentralisierten Bundesvollzugs («layer cake» federalism) (**1 Punkt**) vor, wo Bund und Gliedstaaten je für sich den Vollzug ihres eigenen Rechts besorgen (**1 Punkt**).

Vorliegend sind gemäss Art. 3 des Bundesgesetzes über das Gesichtsverhüllungsverbot die Kantone zuständig für den Vollzug. Es handelt sich damit um ein typisches Beispiel des Vollzugsföderalismus (**1 Punkt**).

*Fortsetzung des Sachverhalts*

Lisa Mader möchte als strenggläubige Muslima nicht ohne Niqab – ein Kleidungsstück, das den ganzen Körper sowie bis auf die Augen auch das Gesicht verdeckt – aus dem Haus gehen. Sie trägt das Kleidungsstück daher trotz des Verbots weiterhin in der Öffentlichkeit. Auf einem Spaziergang durch die St.Galler Altstadt wird Lisa Mader von der Polizei angehalten und gestützt auf Art. 1 des Bundesgesetzes über das Gesichtsverhüllungsverbots gebüsst.

Lisa Mader ist verärgert. Sie ist der Meinung, das «Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot» verstosse gegen die Religionsfreiheit, die nicht nur in Art. 15 BV sondern auch in Art. 9 EMRK garantiert ist. (***Hinweis***: Die Schweiz hat die EMRK unterzeichnet und ratifiziert).

**Frage 2:** [6 Punkte]
Welche Systeme betreffend Geltung von Völkerrecht und Landesrecht existieren? Kann Art. 9 EMRK in der Schweiz innerstaatliche Geltung beanspruchen?

Das dualistische System (**1 Punkt**) fordert, dass Völkerrecht zuerst durch einen nationalen Rechtsakt in nationales Recht überführt werden muss (**1 Punkt**).

Das monistische System **(1 Punkt**) geht demgegenüber von der Einheit der Rechtsordnungen aus (**1 Punkt**) und lässt Völkerrecht für Behörden und Private unmittelbar bindend sein (**1 Punkt**).

Da die Schweiz dem monistischen System folgt und die EMRK unterzeichnet und ratifiziert hat, kann Art. 9 EMRK in der Schweiz innerstaatliche Geltung beanspruchen (**1 Punkt**).

**Frage 3:** [6 Punkte]
Kann sich Lisa Mader vor schweizerischen Gerichten unmittelbar auf Art. 9 EMRK stützen und eine Verletzung dieser Norm geltend machen?

Auch im monistischen System kann nicht jede völkerrechtliche Norm im Einzelfall unmittelbar angerufen werden («*self-executing*») (**1 Punkt**). Damit sich Private wie Lisa Mader auf völkerrechtliche Bestimmungen stützen können, müssen diese den Privaten individuelle Rechte und Pflichten vermitteln (**1 Punkt**) und zudem genügend bestimmt zur direkten Anwendung durch Verwaltung und Justiz sein (**1 Punkt**).

Die Garantien der EMRK gewähren dem Individuum selbst durchsetzbare Rechtsansprüche («Jede Person hat das Recht …») und ist genügend bestimmt (**2 Punkte**).

Art. 9 EMRK ist daher *self-executing* und Lisa Mader kann sich vor Gericht direkt darauf stützen (**1 Punkt**).

***Hinweis***: Gehen Sie für die folgende Frage davon aus, dass Lisa Mader vor schweizerischen Gerichten direkt eine Verletzung von Art. 9 EMRK geltend machen kann.

**Frage 4:** [5 Punkte]
Nachdem sie die kantonalen Instanzen erfolglos durchlaufen hat, möchte Lisa Mader vor Bundesgericht eine Verletzung von Art. 9 EMRK durch das «Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot» geltend machen.

Wie äusserte sich das Bundesgericht bisher in solchen Fällen? Wie würden Sie als Anwältin oder Anwalt von Lisa Mader vor Bundesgericht argumentieren?

Zum Verhältnis von Bundesgesetzen gegenüber Völkerrecht gibt es zwei Rechtsprechungslinien des Bundesgerichts.

Nach der sog. «Schubert-Praxis» geht eine bundesgesetzliche Norm im Konfliktfall vor, wenn der Gesetzgeber einen allfälligen Konflikt mit dem Völkerrecht bewusst in Kauf genommen hat (**1 Punkt**). Nach der sog. «PKK-Praxis» geht Völkerrecht dem Landesrecht «prinzipiell» vor (**1 Punkt)**, insbesondere dann, wenn die völkerrechtliche Norm «dem Schutz der Menschenrechte dient» (**1 Punkt**). Die Mehrheit der neueren Entscheidungen folgt tendenziell der «PKK-Praxis» (**1 Bonuspunkt**).

Als Anwältin/Anwalt von Lisa Mader würde ich geltend machen, Art. 9 EMRK sei eine völkerrechtliche Norm, die dem Schutz von Menschenrechten dient **(1 Punkt)**. Als solche geht sie im Konfliktfall im Sinne der «PKK-Praxis» dem «Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot» vor **(1 Punkt)**.

*Vgl. BGE 99 Ib 39 (Schubert-Praxis), BGE 125 II 417 (PKK-Praxis)*

## Aufgabe 3 — 19 Punkte

*Der Sachverhalt ist frei erfunden!*

Der St.Galler Lorenz Schlauwiner träumt schon seit seiner Kindheit davon, König über eigene Ländereien und Bürger zu sein. Um sich diesen Traum zu verwirklichen, kaufte er in den vergangenen Jahren diverse Grundstücke und ist mittlerweile stolzer Eigentümer von 55'000 Quadratmetern Land, das sich auf mehrere auseinanderliegende Parzellen im Kanton St.Gallen verteilt. Auf diesem Land gründet Lorenz schliesslich das «Königreich Schlauwinia» und lässt sich vor Freunden und Familienangehörigen zum König krönen. Er druckt eine eigene Währung und lässt eigens für das Königreich Schlauwinia eine Nationalhymne komponieren. Den rund 100 Personen – Freunde und Familienangehörige von Lorenz –, die auf seinen Grundstücken wohnen, lässt er Pässe ausstellen, die ihre Angehörigkeit zum Königreich Schlauwinia attestieren. Damit Lorenz sich gegen potenzielle Feinde des Königreichs wehren kann, kauft er sich eine alte Kanone, die er auf einem seiner Grundstücke zur Abschreckung aufstellt, und ernennt zehn seiner Freunde zum aktiven Militär des Königreichs Schlauwinia. Mit der Hilfe eines Juristen erarbeitet Lorenz auch eine Verfassung für das Königreich, in der Lorenz als alleinherrschender König bezeichnet wird. Als König würde er gerne über seine dort wohnhaften Freunde und Familienmitglieder – die er auch gerne als Untertanen bezeichnet – mit eiserner Faust regieren. Die Behörden nehmen Lorenz' Bemühungen um ein eigenes Königreich nicht ernst. Zur Sicherheit teilen sie ihm aber mit, dass sie auf ihrem Gebiet keine Parallelstaaten dulden.

**Frage 1**: [17 Punkte]
Welche Elemente definieren einen Staat? Erfüllt das «Königreich Schlauwinia» diese Kriterien?

Nach der Dreielementenlehre (**1 Punkt**) von GEORG JELLINEK benötigt ein Staat ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt (**2 Punkte**).

Staatsvolk (insgesamt **3 Punkte**)
Das Staatsvolk ist eine Gruppe von Menschen, die auf dem Staatsgebiet lebt, gemeinsam vom Staat beherrscht wird oder durch ein anderes rechtliches oder politisches Kriterium verbunden ist. Eines dieser Kriterien ist der Wohnsitz: Vorliegend wohnen gemäss Sachverhalt rund 100 Personen im «Königreich Schlauwinia». Zudem stellt Lorenz den Bewohnerinnen und Bewohnern Pässe aus.
*Fazit*

Das Staatsgebiet ist ein Stück Erde, über das der Staat seine Herrschaft ausübt (**1 Punkt**). Vorliegend hat Lorenz Grundstücke privatrechtlich erworben und verfügt damit über ein abgrenzbares Stück Land. Bei einem privatrechtlichen Verkauf wird indes bloss *dominium* übertragen, nicht aber *imperium* (also die öffentlich-rechtliche

Gebietshoheit) (**2 Punkte**). Das Land, das Lorenz gekauft hat, gehört also immer noch zum Hoheitsbereich der Schweiz und kann nicht als «Staatsgebiet» des «Königreichs Schlauwinia» qualifiziert werden (**1 Punkt, Fazit**). Zudem sieht das Völkerrecht heute *kein Sezessionsrecht* vor, also keine Möglichkeit, dass auf dem Gebiet eines bereits anerkannten Staates (hier der Schweiz) ohne Zustimmung dieses Muttergemeinwesens ein neuer Staat entsteht (**Zusatzpunkte**).

Die Staatsgewalt ist die Herrschaft, die der Staat ausübt (**1 Punkt**). Das «Königreich Schlauwinia» will seine Herrschaft gestützt auf eine sich selbst gegebene Verfassung ausüben (**1 Punkt**). Es liegt also originäre Herrschaftsgewalt im Sinne von FLEINER und JELLINEK vor (**1 Punkt**). Stellt man dagegen auf das Konzept der inneren und äusseren Souveränität gemäss HOBBES und BODIN ab, ist die Staatsgewalt zu verneinen (**1 Punkt**). Nach dem Effektivitätsprinzip ist nicht von einer tatsächlichen, von der Schweiz hingenommenen Kontrolle des Gebiets durch das «Königreich Schlauwinia» auszugehen (**1 Punkt**). Zudem lassen Lorenz' Aktionen die äussere Souveränität der Schweiz als Völkerrechtssubjekt unangetastet (**1 Punkt**).

**Zusatzpunkte** (max. + 2 Punkte) für sinnvolle Ausführungen (Definition und Argumentation) betreffend legitime/legale Herrschaft als zusätzliche Kriterien der Staatsgewalt.

Gesamtfazit (**1 Punkt**).

**Frage 2**: [2 Punkte]
Ist die Anerkennung durch andere Staaten relevant für die Frage, ob das «Königreich Schlauwinia» als Staat zu qualifizieren ist?

Nein, konstitutiv für einen Staat ist nur das Vorliegen der nach Frage 1 notwendigen Elemente (**1 Punkt**). Der Anerkennung kommt bloss deklaratorische Bedeutung zu (**1 Punkt**).

**Zusatzpunkt** (max. + 0.5 Punkte) für die Erwähnung, dass die Anerkennung durch andere Staaten der Aufnahme diplomatischer Beziehungen dient.

## Aufgabe 4 — 23 Punkte

Der Bundesrat hatte im März 2020 gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV eine Notverordnung für den Kultursektor erlassen (nachfolgend: Covid-Verordnung Kultur). Diese Verordnung hatte zum Zweck, durch die Covid-19-Pandemie entstandene wirtschaftliche Schäden im Schweizer Kultursektor abzufedern. Dazu sah die Verordnung unter anderem vor, dass Kulturunternehmen auf Gesuch hin finanzielle Soforthilfe erhalten. Gesuche waren bei den kantonalen Behörden einzureichen.

Die Pyro AG mit Sitz in Lausanne (Kanton Waadt) ist auf die Organisation von Feuerwerken spezialisiert. Einen Grossteil ihres Umsatzes verdient die Pyro AG jeweils mit Feuerwerken, die sie am 1. August (dem Bundesfeiertag) an zahlreichen Festivitäten inszeniert. Im Jahr 2020 musste die Mehrheit dieser Feierlichkeiten (inklusive Feuerwerkshows) wegen der Covid-19-Pandemie aber abgesagt werden, weshalb die Pyro AG in einen akuten finanziellen Engpass geriet. Deshalb reichte die Pyro AG bei der zuständigen kantonalen Stelle (Kulturdepartement des Kantons Waadt) ein Gesuch um Entschädigung für die erlittenen Verluste ein.

Die kantonale Stelle wies das Gesuch der Pyro AG nach vorgängiger Anhörung jedoch mit der Begründung ab, dass pyrotechnische Unternehmen nicht zum Kultursektor im Sinne der Covid-Verordnung Kultur gehörten. Die Pyro AG ist gar nicht zufrieden mit diesem Entscheid. Sie ist der Meinung, dass Feuerwerkshows am 1. August sehr wohl zur Schweizer Kulturlandschaft gehören.

**Frage 1**: [13 Punkte]
Verschafft ein Verfahrensgrundrecht aus der Bundesverfassung der Pyro AG einen Anspruch darauf, gerichtlich gegen den Entscheid des kantonalen Kulturdepartements vorzugehen?

Für den vorliegenden Fall einschlägig ist die Rechtsweggarantie des Art. 29*a* BV (**1 Punkt**). Adressat dieses Grundrechts ist das Gericht (**1 Punkt**), das als staatliche Behörde ein zulässiger Grundrechtsadressat ist (**1 Punkt**). Auf die Rechtsweggarantie können sich sowohl natürliche wie auch juristische Personen berufen (**1 Punkt**), die Pyro AG ist mithin Trägerin des Grundrechts (**1 Punkt**). In sachlicher Hinsicht verlangt Art. 29*a* BV, dass eine Rechtsstreitigkeit vorliegt (**1 Punkt**), die nicht ausnahmsweise gesetzlich ausgeschlossen ist (**1 Punkt**).

Eine Rechtsstreitigkeit liegt vor, wenn ein Sachverhalt vom Verfassungs-, Gesetzes- und/oder Verordnungsrecht erfasst wird oder ein Beschwerdeführer dies behauptet und wenn es um Interessen geht, die vom Recht als «schützenswert» anerkannt sind (**1 Punkt**). Solche Interessen sind z.B. anzunehmen, wenn dem betroffenen Privaten Pflichten auferlegt oder Rechte eingeräumt/verweigert werden (**1 Punkt**).

Vorliegend sieht das Verordnungsrecht vor, dass Kulturunternehmen auf Gesuch Finanzhilfen erhalten. Die Pyro AG macht geltend, dass sie ebenfalls in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt und ihr die Finanzhilfen daher zu Unrecht verweigert wurden. Mithin stützt sich die Pyro AG auf eine Rechtsnorm und ist aufgrund der Umsatzeinbussen in schützenswerten Interessen betroffen. Dem bisherigen Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass die richterliche Beurteilung gesetzlich ausgeschlossen wäre **(3 Punkte).**

**Fazit** (**1 Punkt**).

**Frage 2**: [6 Punkte]

*Zusatz zum obigen Sachverhalt*:

Der letzte Artikel der einschlägigen Covid-Verordnung Kultur lautete wie folgt:

*Gegen Entscheide in Vollzug dieser Verordnung stehen keine Rechtsmittel offen.*

In den amtlichen Ausführungen dazu heisst es: Da die Geltungsdauer der Covid-Verordnung Kultur sowieso nur eine sehr kurze Geltungsdauer von sechs Monaten habe, rechtfertige es sich, jegliche gerichtliche Überprüfung von Entscheiden auszuschliessen. Zudem sei es in diesen «unruhigen Zeiten» wichtig, schnell konkrete Massnahmen gegen die Pandemie zu treffen, ohne dass die Behörden durch Beschwerden gegen ihre Entscheide gelähmt würden.

Ist dieser Ausschluss des Rechtsschutzes verfassungsmässig haltbar? Nennen Sie zwei Argumente.

**Max. 6 Punkte**:
Gemäss Art. 29*a* Satz 2 BV können Bund und Kantone durch Gesetz die richterliche Beurteilung von Rechtsstreitigkeiten in Ausnahmefällen ausschliessen.

Der Verweis auf «unruhige Zeiten» rechtfertigt es vorliegend nicht, jeglichen (gerichtlichen) Rechtsschutz unter der Covid-Verordnung Kultur auszuschliessen. Gerade bei (gesetzesvertretenden) Notverordnungen, die der Bundesrat ohne Mitwirkung des Parlaments erlassen kann, kommt dem gerichtlichen Rechtsschutz (auch als Aspekt der Gewaltenteilung) eine fundamentale Bedeutung zu. *Vgl. BGE 147 I 333 E. 1.6.3 f.*

Es lässt sich zudem argumentieren, dass ein allfälliger Ausschluss der Rechtsweggarantie im Gesetz selbst vorgesehen sein muss (vgl. Wortlaut von Art. 29*a* BV) und Notverordnungen nicht genügen. So *Brunner/Wilhelm/Uhlmann, AJP 2020, S. 696*.

**Zusatzpunkte**: Als Ausnahme der Rechtsweggarantie kommen gemäss Lehre und Praxis nur schwer «justiziable» Akte in Frage (bspw. «actes de gouvernements», die im Wesentlichen *politische* Fragen betreffen). Vorliegend deutet nichts darauf hin, dass der Vollzug der Covid-Verordnung Kultur eminent politische Fragen aufwerfen würde, die das Interesse an Rechtsschutz in den Hintergrund rücken könnten (*BGE 147 I 333 E. 1.6.2*).

**Frage 3**: [4 Punkte]
Kann die Pyro AG die Verfassungsmässigkeit der Covid-Verordnung Kultur gerichtlich überprüfen lassen?

Verordnungen des Bundesrates können in der Schweiz nicht direkt angefochten werden (vgl. Art. 189 Abs. 4 BV) (**1 Punkt**). Im Zusammenhang mit einem konkreten Rechtsanwendungsakt können Verordnungen des Bundesrates allerdings vorfrageweise auf ihre Rechtmässigkeit (inkl. Verfassungsmässigkeit) überprüft werden (akzessorisches Prüfungsrecht) (**1 Punkt**).

Vorliegend wurde der Pyro AG die Finanzhilfe in Anwendung der Covid-Verordnung Kultur verweigert. In diesem Zusammenhang kann also die Verfassungsmässigkeit der Covid-Verordnung Kultur gerichtlich überprüft werden. (**Subsumtion, 1 Punkt**).

Art. 190 BV steht einer solchen Überprüfung nicht entgegen, weil sich die Verordnung vorliegend gemäss Sachverhalt nicht auf ein Bundesgesetz, sondern unmittelbar auf die Verfassung stützt (**1 Punkt**).

Universität St.Gallen

# Prüfungsbooklet Assessment

## Rechtswissenschaft I B

### Teil Schmid

**Hinweise:**

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

# Prüfung Assessmentjahr – Frühjahrssemester 2022

**Name:** | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

---

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**
**2,170**

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

---

Verantwortlich: **Prof. Dr. Benjamin Schindler**

---

## Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst 4 Aufgaben auf 16 Seiten (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

| | |
|---|---|
| Aufgabe 1 | 20 Punkte |
| Aufgabe 2 | 30 Punkte |
| Aufgabe 3 | 10 Punkte |
| Aufgabe 4 | 30 Punkte |
| **Total** | **90 Punkte** |

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz unterhalb der Fragen nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie ganze Sätze und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

## Aufgabe 1: Dringliche Gesetzgebung und direkte Demokratie (20 Punkte)

Lesen Sie folgenden Zeitungsartikel von Ende Januar 2022 und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

**Komitee will Volks- und Ständemehr bei dringlichen Bundesgesetzen**

Ein vom Parlament verabschiedetes und für dringlich erklärtes Bundesgesetz soll in jedem Fall Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet werden. Das fordert eine neue Volksinitiative.

Das Volksbegehren wurde bei der Bundeskanzlei zur Vorprüfung eingereicht, wie dem «Bundesblatt» am Dienstag zu entnehmen war. Die Initiative trägt den Titel «Volk und Stände entscheiden über dringlich erklärte Bundesgesetze».

Konkret soll in der Bundesverfassung verankert werden, dass ein dringliches Bundesgesetz hundert Tage nach Annahme durch die Bundesversammlung ausser Kraft tritt, wenn es nicht innerhalb dieser Frist von Volk und Ständen angenommen wird.

Das Komitee hat nun bis am 25. Juli 2023 Zeit, die nötigen Unterschriften zu sammeln. Unter den elf angegebenen Urheberinnen und Urhebern der Initiative befinden sich keine bekannten politischen Persönlichkeiten, dafür ein Genfer Physiker und ein Genfer Dirigent.

Die Gültigkeit der Initiative wird erst nach ihrem allfälligen Zustandekommen […] geprüft. Seit der Corona-Pandemie hat das Parlament zahlreiche dringliche Gesetze verabschiedet, darunter das Covid-19-Gesetz, gegen das zwei Mal das fakultative Referendum ergriffen wurde.

**Frage 1)**

**Im Zeitungsartikel wird erwähnt, dass die Volksinitiative bei der Bundeskanzlei zur Vorprüfung eingereicht wurde. Erklären Sie, worum es sich bei dieser Vorprüfung genau handelt. (3 Punkte)**

*Hierbei handelt es sich um eine rein formelle Prüfung, die in Art. 69 BPR geregelt ist. Die Bundeskanzlei prüft in formeller Hinsicht, ob die Unterschriftenliste den gesetzlichen Vorschriften (vgl. Art. 68 BPR) entspricht (Art. 69 Abs. 1 BPR) und ändert gegebenenfalls den Initiativtitel ab, wenn dieser irreführend ist, kommerzielle oder persönliche Werbung enthält oder zu Verwechslungen Anlass gibt (Art. 69 Abs. 2 BPR). Zudem prüft die Bundeskanzlei die Initiativtexte auf ihre sprachliche Übereinstimmung und nimmt allfällige Übersetzungen vor (Art. 69 Abs. 3 BPR).*

*GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021, § 23 N. 90; § 24 N. 64*

**Frage 2)**

**Weiter wird im Zeitungsartikel erwähnt, dass sich im Initiativkomitee keine bekannten politischen Persönlichkeiten befinden. Äussern Sie sich zur Frage, ob ein Initiativkomitee überhaupt zwingend ist und ob auch eine juristische Person Mitglied eines Initiativkomitees sein kann. (3 Punkte)**

*Ein Initiativkomitee ist vom Gesetz zwingend vorgesehen (Art. 68 Abs. 1 Bst. e, Art. 80 Abs. 3 BPR). Eine juristische Person kann nicht Mitglied eines Initiativkomitees sein, da eine Mitgliedschaft ausschliesslich stimmberechtigten Personen vorbehalten ist (Art. 68 Abs. 1 Bst. e BPR).*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 65*

**Frage 3)**

**Ferner wird im Zeitungsartikel erwähnt, dass die Gültigkeit der Initiative erst nach ihrem allfälligen Zustandekommen geprüft wird.**

**a) Wer prüft das Zustandekommen der Volksinitiative? (2 Punkte)**

*Diese Prüfung obliegt der Bundeskanzlei (Art. 72 Abs. 1 BPR).*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 91; § 24 N. 66*

**b) Wer prüft die Einhaltung der Gültigkeitsvoraussetzungen? (2 Punkte)**

*Diese Prüfung obliegt der Bundesversammlung (Art. 139 Abs. 3 und Art. 173 Abs. 1 Bst. f BV; Art. 98 ParlG; Art. 75 BPR).*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 92*

**Frage 4)**

**Gemäss Zeitungsbericht hat das Parlament während der Corona-Pandemie zahlreiche dringliche Gesetze verabschiedet; dies vor dem Hintergrund, dass der Gesetzgeber rasch auf bestimmte Entwicklungen reagieren musste. Erklären Sie, inwiefern durch den Erlass eines dringlichen Bundesgesetzes im Vergleich zu einem nicht dringlichen Bundesgesetz Zeit gewonnen werden kann. (3 Punkte)**

*Die Besonderheit bei dringlichen Bundesgesetzen (Art. 165 BV; vgl. auch Art. 77 ParlG) besteht in erster Linie darin, dass diese nach ihrer Verabschiedung im Parlament sofort in Kraft gesetzt werden können, ohne dass vorgängig die Referendumsfrist und eine allfällige Referendumsabstimmung abgewartet werden müssen. Die für die Beurteilung der Dringlichkeit massgebliche Zeitdauer ist die gesetzliche Referendumsfrist von 100 Tagen und die für die allenfalls notwendige Volksabstimmung erforderliche Zeit, mithin ein Zeitrahmen von etwa sechs bis zwölf Monaten.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 48 ff.*

**Frage 5)**

**Das Initiativkomitee will in der Bundesverfassung die Regelung verankern, wonach sämtliche dringlichen Bundesgesetze einem obligatorischen Referendum unterliegen sollen. Nennen Sie je ein Argument für und gegen eine solche Regelung. (3 Punkte)**

*Pro:*

*Annahme der Initiative*

- *würde die Volksrechte bzw. Referendumsdemokratie stärken*
- *würde die Macht des Parlaments einschränken*
- *als Antwort auf die Negativerfahrungen während Corona-Pandemie (z.B. bei Art. 10a ParlG)*

*Contra:*

*Gegen die Volksinitiative spricht, dass*

- *ein obligatorisches Referendum gegen sämtliche dringlichen Bundesgesetze sehr aufwändig wäre. Während der Corona-Pandemie hätte es über ein Dutzend obligatorische Abstimmungen gegeben.*
- *bei unterjährigen Bundesgesetzen eine Volksabstimmung aus zeitlichen Gründen u.U. faktisch unmöglich ist.*
- *eine Kategorisierung von Gesetzen eingeführt würde («normale Gesetze» mit fak. Referendum und «dringliche Gesetze» mit obl. Referendum und Doppelmehr).*
- *das Ständemehr bei Bundesgesetzen sehr untypisch ist bzw. ein Bundesgesetz im Verfahren der Verfassungsgebung behandelt würde.*
- *die Rechtsunsicherheit zunehmen würde.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 48 ff.*
*Hinweis: Hier geht es vor allem darum, dass die Studierenden ihr im Kurs erworbenes Wissen anwenden können und überzeugend argumentieren!*

**Frage 6)**

**Auch unter dem zurzeit geltenden Recht gibt es eine Art von Bundesgesetz, das einem obligatorischen Referendum mit dem Erfordernis des Doppelmehrs von Volk und Ständen untersteht. Nennen Sie diese Art und erklären Sie, was Sinn und Zweck dieser Regelung ist. (4 Punkte)**

*Es handelt sich dabei um dringliche Bundesgesetze, die über keine Verfassungsgrundlage verfügen (Art. 165 Abs. 3 BV) und zudem auf mehr als ein Jahr befristet («überjährig») sind. Eine Verfassungsgrundlage fehlt etwa, wenn der Bund im zu regelnden Gebiet keine Kompetenz besitzt. Da diesen Erlassen insofern die Verfassungsgrundlage fehlt und sie daher materiell die Verfassung ändern, unterstehen sie einem nachträglichen obligatorischen Referendum, bei dem eine Mehrheit von Volk und Ständen erforderlich ist (Art. 140 Abs. 1 Bst. c BV).*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 55 f.*

## Aufgabe 2: Vergrösserung des Bundesrates? (30 Punkte)

Lesen Sie folgenden Zeitungsartikel von Ende November 2021 und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

### Neuer Anlauf: Nationalrat will Bundesrat auf neun Mitglieder vergrössern

Der Nationalrat hat am Montag mit 102 zu 79 Stimmen einer parlamentarischen Initiative Folge gegeben, die eine Vergrösserung des Bundesrates auf neun Mitglieder fordert. Die parteipolitische Zusammensetzung des Gremiums würde die Kräfteverhältnisse im Parlament bedeutend weniger gut abbilden als früher, befand die Mehrheit aus den Reihen der SP, Grünen, GLP und Die Mitte.

Aus ihrer Sicht könnten die zunehmenden Regierungsaufgaben auf mehr Schultern verteilt und die einzelnen Regierungsmitglieder entlastet werden. Seit Beginn des Bundesstaates besteht die schweizerische Regierung unverändert aus sieben Mitgliedern. Nur Liechtenstein habe weniger Regierungsmitglieder, betonte Initiantin Nadine Masshardt (SP/BE) im Nationalrat.

**Widerstand in der kleinen Kammer gewiss**

Anders sah das die Minderheit. Sie erachtet es der politischen Stabilität abträglich, wenn aufgrund geänderter Kräfteverhältnisse im Parlament die Grösse der Regierung geändert wird. Der Bundesrat sei kein Proporzgremium, stellte Kurt Fluri (FDP/SO) klar. Vorrang habe das Kollegialitätsprinzip. Die Minderheit aus den Reihen der FDP und SVP führte auch den steigenden Koordinationsbedarf zwischen den Departementen ins Feld, was wiederum eine Mehrbelastung bedeute.

Trotz dem nationalrätlichen Ja dürfte der parlamentarischen Initiative ein kurzes Leben beschert sein. Die zuständige Kommission des Ständerates lehnte das Ansinnen bei einer ersten Beratung deutlich ab. Aus Erfahrung wird sich in der kleinen Kammer kaum ein Sinneswandel ereignen. Vor fünf Jahren ist ein Anlauf bereits schon einmal gescheitert.

**Frage 1)**
**Nationalrat Kurt Fluri sprach sich gegen die parlamentarische Initiative aus. Seiner Meinung nach ist der Bundesrat kein «Proporzgremium». Inwiefern spielt der Parteienproporz, das heisst die verhältnismässige Vertretung der wichtigsten politischen Kräfte, aber trotzdem eine wichtige Rolle für die Wahl des Bundesrates? (4 Punkte)**

*Die sog. Zauberformel schlüsselt die sieben Sitze im Bundesrat auf die wichtigsten Parteien in der Schweiz nach ihrer Wählerstärke auf. 1959 verständigte man sich darauf, dass der Bundesrat fortan im Verhältnis 2:2:2:1 aus Vertretern der vier wählerstärksten Parteien zusammengesetzt sein soll. Nach einigen Jahren Unterbruch ist die Bundesversammlung 2015 wieder zur Zauberformel zurückgekehrt, wonach die SVP, die FDP und die SP je zwei Bundesratsmitglieder stellen, die ehemalige CVP und heutige «Die Mitte» ein Mitglied. Bei der Zauberformel handelt es sich um eine dem Konkordanzdenken verpflichtete politische Übereinkunft ohne rechtliche Verbindlichkeit.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 19 N. 23 ff.*

**Frage 2)**
**Nennen Sie eine Fraktion, welche in der 51. Legislaturperiode der Bundesversammlung (2019–2023) nicht im Bundesrat vertreten ist. (1 Punkt; Nennung genügt, keine Begründung erforderlich)**

*Mögliche Antworten:*
- *Grüne Fraktion*
- *Grünliberale Fraktion*

*Vorlesung 2/IV Folien 38 ff.*

**Frage 3)**
**Aus dem Zeitungsartikel geht hervor, dass die Bundesversammlung aus zwei «Kammern» besteht. Nennen und erläutern Sie zwei Funktionen des Schweizer Zweikammersystems. (4 Punkte)**

- *Föderative/bundesstaatliche Funktion: Das Zweikammersystem der Bundesversammlung entspricht der Repräsentation von Volk (Nationalrat) und Gliedstaaten (Ständerat).*
- *Diskursive Funktion/Verbesserung der parlamentarischen Beratung: Die mehrfache Beratung in unterschiedlich zusammengesetzten Kammern erlaubt differenzierte Abwägungen und erhöht damit auch die Chance von längerfristig tragfähigen Lösungen.*
- *Gewaltenteilige/rechtsstaatliche Funktion: Das Zweikammersystem kann schliesslich auch die Funktion der Gewaltenteilung innerhalb der Legislative haben. Die Vorrangstellung der Volkskammer wird durch eine zweite Kammer abgeschwächt. Die zweite Kammer soll die Volkskammer, die eher von der rasch wechselnden Volksmeinung geprägt ist und eher zu überstürzten Beschlüssen neigt, etwas «bremsen». Die Gewaltenteilung innerhalb der Legislative kann zu einer gewissen Schwächung des Parlaments und damit einhergehend zu einer Stärkung der Regierung führen.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 7 f.*
*Vorlesung 2/IV Folie 13*

**Frage 4)**
**Im Zeitungsartikel wird der Ständerat als «<u>kleine</u>» Kammer bezeichnet. Weshalb? (3 Punkte)**

*Anders als der Nationalrat, der sich aus 200 Mitgliedern zusammensetzt (Art. 149 Abs. 1 BV), besteht der Ständerat aus lediglich 46 Mitgliedern (Art. 150 Abs. 1 BV).*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 18 ff., 25 ff.*

**Frage 5)**

**Ferner wird im Zeitungsartikel geschrieben, dass dem Vorstoss ein kurzes Leben beschieden sein werde, da die zuständige Kommission des Ständerats den Vorschlag ablehne und die kleine Kammer erfahrungsgemäss keinen Sinneswandel vollziehen werde. Weshalb ist die Zustimmung auch des Ständerats zwingend? (3 Punkte)**

*Das Zweikammersystem der Bundesversammlung ist durch die grundsätzliche Gleichstellung der beiden Räte geprägt (Art. 148 Abs. 2 BV), weshalb Beschlüsse der Bundesversammlung die Übereinstimmung beider Räte erfordern (Art. 156 Abs. 2 BV).*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 8, 81.*

**Frage 6)**

**Es kommt nicht selten vor, dass National- und Ständerat gegenteiliger Meinung sind. Dies liegt mitunter an der unterschiedlichen parteipolitischen Zusammensetzung der beiden Kammern. Weshalb unterscheidet sich die parteipolitische Zusammensetzung des Ständerates von derjenigen des Nationalrates so stark? (6 Punkte)**

*Hauptgrund sind die verschiedenen Wahlsysteme: Gemäss Art. 149 Abs. 2 BV gilt bei Nationalratswahlen der Grundsatz des Proporzes, wobei die nähere Ausgestaltung des Proporzwahlrechts dem Gesetzgeber überlassen bleibt (vgl. Art. 40 und 41 BPR). Für die Kantone, denen aufgrund ihrer Bevölkerungszahl nur ein Nationalratssitz zusteht, erfolgt die Wahl zwangsläufig nach Majorz.*

*Das Wahlverfahren des Ständerates bestimmt sich nach kantonalem Recht (Art. 150 Abs. 3 BV). Mit Ausnahme der Kantone Jura und Neuenburg, wo nach Proporz gewählt wird, haben sich die Kantone für das Majorzverfahren entschieden, wobei sie für den ersten Wahlgang jeweils die Erreichung des absoluten Mehrs verlangen. Als Folge des Majorzwahlystems weist auch die parteipolitische Zusammensetzung recht deutlich von jener des Nationalrats ab. Generell dominieren die grösseren Parteien bzw. Parteien, die eher der gemässigten Mitte zugeordnet werden. Die Parteien, die politisch eher in der Mitte stehen (z.B. FDP und die Mitte), sind im Ständerat übervertreten, während es für «Polparteien» tendenziell schwieriger ist einen Sitz zu erlangen, was sich z.B. an der Untervertretung der SVP zeigt.*

*Ein weiterer Grund ist in der Zusammensetzung des Ständerats zu finden: Die der föderalistischen Struktur geschuldete Verteilung der Ständeratssitze unabhängig von der Bevölkerungszahl beeinträchtigt die demokratische Gleichheit, geht doch die Hälfte der Sitze an (eher ländlich geprägte bzw. flächenmässig kleine) Kantone, die nur rund einen Fünftel der Gesamtbevölkerung ausmachen.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 16, 27*

**Frage 7)**
**Bedürfte eine Erhöhung der Anzahl Mitglieder des Bundesrats zwingend auch der Zustimmung von Volk und Ständen? (3 Punkte)**

*Ja. Es müsste Art. 175 Abs. 1 BV geändert werden. Änderungen der Bundesverfassung unterliegen stets einem obligatorischen Referendum (140 Abs. 1 Bst. a BV) mit Doppelmehrerfordernis.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 19 N. 9 f., § 24 N. 14 f.*

**Frage 8)**
**Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen zu den Bundesratswahlen:**

**a) Ist es rechtlich zwingend, dass mindestens ein Mitglied des Bundesrates aus der italienischsprachigen Schweiz stammt? (3 Punkte)**

*Nein. Die Bundesversammlung hat bei der Wahl lediglich «darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind (Art. 175 Abs. 4 BV). Es geht dabei weder um die Vertretung im herkömmlichen Rechtssinn noch um die Repräsentation im staats- bzw. verfassungstheoretischen Sinn. Die vom Verfassungsgeber gewählte Wortwahl («Rücksicht nehmen»; «angemessen») macht deutlich, dass es keine festen rechnerischen Quoten oder gar «Vertretungs»-Ansprüche gibt.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 19 N. 17*

**b) Dürften Vater und Sohn gleichzeitig dem Bundesrat angehören? (3 Punkte)**

*Nein. Die Unvereinbarkeiten sind in Art. 144 BV geregelt, wobei gemäss Abs. 3 das Gesetz weitere Unvereinbarkeiten vorsehen kann. Zur Vermeidung von Abhängigkeit und Interessenkonflikten sieht der Gesetzgeber bestimmte familiär bedingte Unvereinbarkeiten vor. Nahe Verwandte (z.B. wie hier Verwandtschaft in gerader Linie) dürfen gemäss Art. 61 Abs. 1 Bst. b RVOG nicht gleichzeitig dem Bundesrat angehören.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 19 N. 89*
*Vorlesung 2/IV Folie 13*

## Aufgabe 3: Gespräch über die Wirtschaftsfreiheit (10 Punkte)

Helena beginnt im September das Assessmentjahr an der HSG. Sie freut sich bereits jetzt sehr auf ihr BWL-Studium. Als angehende BWL-Studentin interessiert sie sich im Bundesstaatsrecht vor allem für die Wirtschaftsfreiheit. Sie sitzen mit Helena in einer Bar und diskutieren bereits jetzt über derartige Themen. Dabei behauptet Helena so allerlei. Nehmen Sie zu jeder Aussage Stellung, und legen Sie dar, inwiefern diese zutrifft oder nicht zutrifft.

**Aussage 1)**
**Gemäss der institutionellen Funktion der Wirtschaftsfreiheit hat der Bund einen einheitlichen Wirtschaftsraum zu schaffen. (2 Punkte)**

*Falsch. Gemäss der institutionellen Funktion der Wirtschaftsfreiheit haben sich Bund und Kantone an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 94 Abs. 1 BV) zu halten, wobei die ordnungspolitische Grundentscheidung für eine marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaft zu beachten ist. Einen einheitlichen Wirtschaftsraum hat der Bund aufgrund der bundesstaatlichen Funktion der Wirtschaftsfreiheit zu schaffen (vgl. Art. 95 Abs. 2 BV).*

*Vorlesung 2/III Folien 13 ff.*

**Aussage 2)**
**Natürliche Personen können sich nur dann auf die Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV berufen, wenn sie Schweizer Staatsangehörige sind. (2 Punkte)**

*Falsch. Auf die Wirtschaftsfreiheit können sich ausländische natürliche Personen berufen, wenn sie in der Schweiz niedergelassen sind oder einen gesetzlichen oder staatsvertraglichen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz haben.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 36 N. 13 f.*
*Vorlesung 2/III Folie 16*

**Aussage 3)**

**Die Prostitution fällt unter den sachlichen Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV. (2 Punkte)**

*Richtig. Die Wirtschaftsfreiheit schützt jede privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit, wobei die Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 Abs. 2 BV insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freien Ausübung schützt. Sie umfasst alle auf Erwerb gerichteten Tätigkeiten – unabhängig von der «moralischen Akzeptanz» einer Tätigkeit –, also selbständige und unselbständige, haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 36 N. 2 ff.*
*Selbststudium Fragenkatalog 5 Frage 1d*

**Aussage 4)**

**Eine Bewilligungspflicht für die selbständige Ausübung als Chiropraktikerin ist eine grundsatzkonforme Massnahme. (2 Punkte)**

*Richtig. Wirtschaftspolizeiliche Massnahmen gelten i.d.R. als grundsatzkonform, da ihr Regelungsmotiv in erster Linie nicht darin besteht, sich gegen den Wettbewerb zu richten.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 36 N. 21 ff.*
*Vorlesung 2/III Folie 23*

**Aussage 5)**

**Autoverkäufer und Fahrradverkäufer wären im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts als «direkte» Konkurrenten anzusehen. (2 Punkte)**

*Falsch. Als direkte Konkurrenten gelten lediglich die Angehörigen der gleichen Branche, die sich mit gleichen Angeboten an dasselbe Publikum richten, um das gleiche Bedürfnis zu befriedigen.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 36 N. 17 ff.*
*Selbststudium Fragenkatalog 5 Frage 9*

## Aufgabe 4: Fussball-Weltmeisterschaft! (30 Punkte)

Schon bald ist wieder Fussball-Weltmeisterschafts-Zeit! Viele der 18- bis 20-jährigen Schüler der kantonalen (öffentlichen) Berufsschule im Kanton Y sind schon jetzt in grosser Feierlaune und kommen immer wieder mit Trikots ihrer jeweiligen Lieblingsnationalmannschaft in den Unterricht. Die vielen unterschiedlichen Nationalmannschaftstrikots bringen zwar Farbe in die Klassenzimmer, verursachen allerdings auch gegenseitige Provokationen und Beleidigungen. Dadurch wird der Unterricht in einem solchen Mass gestört, dass die Schulleitung schliesslich den Schülerinnen und Schülern das Tragen der Nationalmannschaftstrikots auf dem gesamten Schulgelände untersagt.
Santiago, der im Kanton Y wohnt und die Berufsschule besucht, ist argentinischer Staatsbürger und ein grosser Fan der argentinischen Fussballnationalmannschaft. Er entscheidet sich am nächsten Tag, trotz des Verbots ein Fussballtrikot seines Landes zu tragen. Als er in der Schule ankommt, verfügt die Schulleitung gestützt auf Art. 47 des Berufsschulgesetzes des Kantons Y sogleich, dass er für den Rest des Monats (rund drei Wochen) vom Unterricht ausgeschlossen werde.

Art. 47 des Berufsschulgesetzes des Kantons Y, das vom hierfür zuständigen Kantonsrat (= Parlament des Kantons Y) erlassen wurde, lautet wie folgt:

> **Art. 47 Pflichten der Schülerinnen und Schüler**
> [1] […]
> [2] Die Schülerinnen und Schüler begegnen den Lehrpersonen, dem Schulpersonal und den Schulbehörden sowie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit Respekt.
> [3] Sie besuchen die Schule in korrekter Kleidung und mit unverhülltem Gesicht.
> [4] Gegen Schülerinnen und Schüler, die selbstverschuldet gegen gesetzliche Vorschriften verstossen, insbesondere dem Unterricht fernbleiben, den Unterricht oder den Schulbetrieb stören oder andere oben genannte Pflichten verletzen, können angemessene Disziplinarmassnahmen getroffen werden.

Santiago ist empört. Seiner Meinung nach hat er als «wahrer Patriot» das Recht, auch weiterhin in der Schule das Nationalmannschaftstrikot zu tragen. Er gelangt deshalb an Sie mit der Frage, ob eine Verletzung seiner Grundrechte vorliege.

- Prüfen Sie anhand der Prüfkriterien, ob ein Grundrechtsfall vorliegt und ob die Voraussetzungen für die zulässige Einschränkung eines Freiheitsrechts erfüllt sind.
- Gehen Sie bei der Prüfung der Grundrechtsrelevanz mit Ausnahme der Wirtschaftsfreiheit auf **alle Freiheitsrechte der Bundesverfassung** ein, die im vorliegenden Fall berührt/tangiert sein könnten. Konzentrieren Sie sich bei der nachfolgenden Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung aber auf **nur ein einziges berührtes Freiheitsrecht.**
- Prüfen Sie alle Kriterien, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.
- Prozessuale Fragen können Sie weglassen.

**Wichtiger Hinweis**: Auf die Wirtschaftsfreiheit ist **nicht** einzugehen!

# *Prüfkriterien 1: Prüfung Grundrechtsrelevanz*

### *a) Rechtsgrundlagen der Freiheitsrechte*

*Im vorliegenden Fall könnten die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) und die Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) berührt sein.*

### *b) Sachlicher Schutzbereich (Schutzobjekt)*

***Persönliche Freiheit:***

*Art. 10 Abs. 2 BV stellt die verfassungsrechtliche Grundgarantie zum Schutz der Persönlichkeit dar und verbrieft neben dem Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit sowie der Bewegungsfreiheit all jene Freiheiten, die elementare Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung darstellen. Das Recht auf persönliche Freiheit ist somit eine umfassende Garantie, die alle elementaren Freiheiten einschliesst, die für die Persönlichkeitsentfaltung unverzichtbar sind.*

***In casu:** Im vorliegenden Fall kann mit guten Gründen argumentiert werden, dass eine derartige Kleiderwahl Ausdruck von Individualität und Persönlichkeit darstellt. Aus diesem Grund zählt eine solche Kleiderwahl zu den elementaren Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung.*

***Fazit:** Der sachliche Schutzbereich der persönlichen Freiheit ist berührt.*

***Meinungsfreiheit:***

*Das Recht auf Meinungsfreiheit (Art. 16 Abs. 2 BV) beinhaltet das Recht jeder Person, sich ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. Geschützt sind alle Mittel, die sich zur Kommunikation eignen (Wort, Schrift, Gebärden, künstlerische Formen usw.). Der Begriff der Meinungsfreiheit ist weit zu verstehen. Er umfasst die Gesamtheit der Mitteilungen menschlichen Denkens, auch Informationen ohne wertenden Gehalt (vgl. Art. 16 Abs. 3 BV) und den Ausdruck von Gefühlen. Eine Meinung fällt unabhängig von ihrem Inhalt in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit.*

***In casu:** Da der Begriff der Meinungsfreiheit weit zu verstehen ist bzw. alle Mittel geschützt sind, die sich zur Kommunikation eignen, kann argumentiert werden, dass mit dem Tragen von Fussballtrikots der jeweiligen Nation eine Meinung geäussert bzw. verbreitet wird; im vorliegenden Fall etwa Nationalstolz («Patriotismus»).*

***Fazit:** Der sachliche Schutzbereich der Meinungsfreiheit ist berührt.*

*Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

### *c) Persönlicher Schutzbereich (Grundrechtsträgerschaft)*

*Die persönliche Freiheit und die Meinungsfreiheit stehen allen natürlichen Personen zu, somit auch den ausländischen, und zwar unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.*

***In casu**: Santiago ist eine natürliche Person.*

***Fazit**: Santiago ist Träger der hier diskutierten Freiheitsrechte.*

### *d) Adressat*

*Adressat der beiden Freiheitsrechte ist der Staat bzw. sind die staatlichen Behörden auf allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit (Bund, Kantone, Gemeinden).*

***In casu:** Bei der Schulleitung handelt es sich um eine staatliche Behörde auf Ebene Kanton.*

***Fazit:** Die Schulleitung ist Adressatin des Grundrechts.*

### *e) Zwischenergebnis der Vorprüfung*

*Es liegt ein Grundrechtsfall vor.*

# *Prüfkriterien 2: Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung (Art. 36 BV)*

## *a) Gesetzliche Grundlage*

*Art. 36 Abs. 1 BV*

*Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Eine Ausnahme bildet die polizeiliche Generalklausel (Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr).*

*Gemäss Art. 47 des kantonalen Berufsschulgesetzes haben Schülerinnen und Schüler korrekte Kleidung zu tragen (Abs. 3). Gegen Schülerinnen und Schüler dürfen Disziplinarmassnahmen erlassen werden, wenn diese ihre Pflichten verletzen.*

*Für Grundrechtseingriffe bei Personen, die in einem besonderen Rechtsverhältnis zu einer staatlichen Einrichtung stehen (sog. Sonderstatusverhältnis), gelten modifizierte Anforderungen an die gesetzliche Grundlage. Unter den Begriff Sonderstatusverhältnis fallen etwa Staatsangestellte, Strafgefangene, Angehörige der Armee, oder auch, wie im vorliegenden Fall, Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen Schule. Insbesondere sind die Anforderungen an die Bestimmtheit der Normen, die den Inhalt des besonderen Rechtsverhältnisses regeln, praxisgemäss gelockert, da sich nicht sämtliche Details im Rahmen eines solchen Verhältnisses im Voraus normieren lassen. Die Bestimmtheit muss aber gleichwohl ausreichen, um eine rechtsgleiche und willkürfreie Behandlung der Personen im besonderen Rechtsverhältnis zu gewährleisten.*

### *Erfordernis des Rechtssatzes*

*Generell-abstrakte Norm: Die Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich in einem Rechtssatz, d.h. in einer generell-abstrakten Norm, vorgesehen sein (Art. 22 Abs. 4 ParlG). Generell ist eine Norm, wenn sie sich an eine unbestimmte Zahl von Adressaten richtet, abstrakt ist eine Norm, wenn sie eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt.*

*Genügende Bestimmtheit: Ein Rechtssatz muss so präzise formuliert sein, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können.*

***In casu:** Art. 47 des kantonalen Berufsschulgesetzes stellt eine generell-abstrakte Norm dar, da der Artikel an eine unbestimmte Zahl von Adressaten richtet und eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt. Die Schülerinnen und Schüler können allerdings ihr Verhalten aufgrund der unpräzisen Formulierung «korrekte Kleidung» nicht danach richten. Es ist unklar und Ansichtssache, was unter «korrekter Kleidung» zu verstehen ist. Die Folgen ihres Verhaltens wiederum, namentlich die bei Pflichtverletzungen drohenden Disziplinarmassnahmen, erscheinen ebenfalls als nicht genügend bestimmt. Hier liegt die ungenügende Bestimmtheit im Ausdruck der «angemessenen Disziplinarmassnahme». Zudem bleibt auch unklar, wer die Disziplinarmassnahmen aussprechen darf. Trotz des Sonderstatusverhältnisses ist die vorliegende Norm zu unbestimmt.*

***Zwischenfazit Erfordernis des Rechtssatzes**: Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt.*

*Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse bezüglich der Bestimmtheit wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

### *Erfordernis der Gesetzesform*

*Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein, d.h. in einem Gesetz im formellen Sinn (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV). Nicht schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen können auch in Erlassen niedrigerer Stufe vorgesehen sein, insbesondere in einer Verordnung.*

***In casu**: Art. 47 des kantonalen Berufsschulgesetzes wurde vom zuständigen Kantonsparlament erlassen. Folglich stellt Art. 47 eine formell-gesetzliche Grundlage dar, weshalb insoweit die Schwere des Grundrechtseingriffs unerheblich ist.*

***Zwischenfazit Erfordernis der Gesetzesform**: Dieses Erfordernis ist erfüllt.*

***Gesamtfazit gesetzliche Grundlage**: Das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage ist aufgrund der ungenügenden Bestimmtheit nicht erfüllt. Art. 47 stellt demnach, obwohl das Erfordernis der Gesetzesform erfüllt ist, keine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Einschränkung der Freiheitsrechte dar.*
*Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

### *b) Rechtfertigende Eingriffsinteressen*

*Art. 36 Abs. 2 BV*
*Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.*
*Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichende öffentliche Interessen gelten z.B. die Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit sowie Treu und Glauben im Geschäftsverkehr). Weitere öffentliche Interessen ergeben sich aus der BV und der Gesetzgebung.*
***In casu:** Im vorliegenden Fall sind die öffentlichen Interessen unter anderem im störungsfreien Unterricht zu finden. Der störungsfreie Unterricht und die mit ihm zusammenhängende Ausbildung von jungen Erwachsenen kann als öffentliches Interesse angesehen werden. Durch die Provokationen und Beleidigungen spielt auch das Polizeigut Ruhe und Ordnung eine gewisse Rolle. Zudem gilt es Grundrechte Dritter zu schützen. Die (persönlichen) Beleidigungen und Provokationen, die im schlimmsten Fall auch zu körperlicher Gewalt führen können, gilt es zu verhindern.*
***Fazit:** Es liegt einerseits ein zulässiges öffentliches Interesse vor. Andererseits gilt es Grundrechte Dritter zu schützen.*

### *c) Verhältnismässigkeit*

*Art. 36 Abs. 3 BV*

***Eignung:***
*Das Gebot, korrekte Kleidung zu tragen, und die konkrete Durchsetzung durch die Schulleitung müssen geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen.*
***In casu**: Das Gebot, korrekte Kleidung zu tragen bzw. das Verbot des Tragens des Nationalmannschaftstrikots einschliesslich Sanktionierung sind ohne weiteres geeignet, Provokationen und Beleidigungen und somit die beanstandete Störung im Unterricht zu verhindern.*
***Fazit:** Die Eignung ist gegeben.*

***Erforderlichkeit:***
*Das Gebot, korrekte Kleidung zu tragen bzw. die konkrete Durchsetzung durch die Schulleitung müssen den geringstmöglichen Eingriff darstellen; es darf keine gleichermassen geeignete, mildere Massnahme geben, die zum gleichen Ziel führen würde. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Beziehung nicht über das Notwendige hinausgehen.*
***In casu**: Das von der Schulleitung verfügte Verbot, Fussballtrikots zu tragen, leitet sich direkt aus der verpflichtenden Norm, korrekte Kleidung zu tragen, ab und erscheint vor diesem Hintergrund gerechtfertigt. Gewisse Kleidungsvorschriften sind zwingend, um den Schulfrieden zu gewährleisten. Allerdings ist das Verbot zu weitgehend, da nicht ersichtlich ist, weshalb das Verbot für das ganze Schulgelände (und nicht nur für die Klassenzimmer) gilt. Nicht rechtmässig erscheint weiter die konkrete Anwendung der Norm durch die Schulleitung betreffend Sanktionierung. Die konkrete Sanktionierung erscheint als zu hart. Die Schulleitung hätte Santiago z.B. ein weiteres Mal verwarnen können, bevor sie einen dreiwöchigen Schulausschluss aussprach. Zudem erscheint auch die Dauer des Schulausschlusses als unverhältnismässig*

*lang. Das Verbot bzw. die Verfügung der Schulleitung geht somit in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Beziehung über das Notwendige hinaus.*
***Fazit:** Die Erforderlichkeit ist nicht gegeben.*
*Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

***Zumutbarkeit:***
*Die Massnahme darf zu keinem Missverhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung führen (Zweck-Mittel-Verhältnis). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Grundrechts muss das private Interesse an dessen ungehinderten Ausübung überwiegen.*
***In casu (Abwägung):***
*Öffentliches Interesse an der Einschränkung: siehe oben.*
*Schutz der Grundrechte von Dritten: siehe oben.*
*Privates Interesse: Interesse von Santiago, das Trikot seiner bevorzugten Nationalmannschaft zu tragen, ohne derartige Sanktionen befürchten zu müssen.*
*Abwägung: Das öffentliche Interesse (störungsfreier Unterricht bzw. Schulfriede) und der Schutz von Grundrechten Dritter (Verhinderung von Beleidigungen und Provokationen) rechtfertigen gewisse Kleidungsvorschriften bzw. das Verbot von Fussballtrikots in den Klassenzimmern. Die harte Sanktionierung (dreiwöchiger Schulausschluss) ist allerdings für Santiago nicht zumutbar. Es bräuchte gewichtigere Interessen, um eine derartige Sanktionierung bzw. einen derartigen Eingriff zu rechtfertigen.*
***Fazit:** Die Zumutbarkeit ist nicht gegeben.*
*Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

***Zwischenergebnis Verhältnismässigkeit**: Die Verhältnismässigkeit der Einschränkung ist im gegebenen Fall zu verneinen.*
*Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

***d) Schutz des Kerngehalts***
*Art. 36 Abs. 4 BV*
*In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Grundrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.*
*Zum Kerngehalt der persönlichen Freiheit gehören das Verbot der Folter und der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung (Art. 10 Abs 3 BV).*
***In casu:** Weder das Kleidungsverbot noch der Ausschluss aus der Schule fallen unter den Kerngehalt der persönlichen Freiheit.*
***Fazit:** Der Kerngehalt der persönlichen Freiheit ist gewahrt.*

*Alternativargumentation, falls die Meinungsfreiheit geprüft wurde:*

*Art. 36 Abs. 4 BV*
*In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Grundrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.*
*Zum Kerngehalt der Meinungsfreiheit gehört die in Art. 16 Abs. 2 angesprochene Freiheit, sich eine Meinung zu bilden (und eine solche zu haben). Absolut verboten sind somit staatliche Massnahmen, die Menschen zur inneren Identifikation mit einer Meinung zwingen (z.B. durch Gehirnwäsche oder den Einsatz von Psychopharmaka).*
***In casu:** Weder das Kleidungsverbot noch der Ausschluss aus der Schule fallen unter den Kerngehalt der Meinungsfreiheit.*
***Fazit:** Der Kerngehalt der Meinungsfreiheit ist gewahrt.*

### *e) Gesamtergebnis*

*Das Kleidungsverbot und der Ausschluss von der Schule stellen einen unzulässigen Eingriff in die Grundrechte von Santiago dar. Es liegt demnach eine Grundrechtsverletzung vor.*
*Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.*

*BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 30 N. 1 ff.; § 31 N. 34 ff.; § 34 N. 1 ff.*
*Hinweis: Hier geht es vor allem darum, dass die Studierenden ihr im Kurs erworbenes Wissen anwenden können und überzeugend argumentieren!*